

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٢ م ، الموافق ٩ رجب
١٤٣٣ هـ ،

برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور
الستري ، وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد
المشهداني ، ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/١١/٧) لسنة (٩) قضائية .

المقامة من:

فينو توماس كوشي

وكيله المحامي د. محمد رضا بوحسين

ضد:

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
- ٢- معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (بصفته) .
- ٣- النيابة العامة.

ويمثلهم جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات

بتاريخ ١٨ من أكتوبر ٢٠١١ ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة
الدستورية طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (٣٦) و(٤٠) من القانون رقم (١٩) لسنة
٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل .

قدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى لاتصالها بالمحكمة الدستورية بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وثانياً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المادة (٤٠) من القانون المذكور ، وثالثاً : برفض الدعوى .

ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من لائحة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية رقم ٠٧/٢٠٠٩/٤٩٠٧ ، ضد المدعي بوصف أنه بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٠٣ بمملكة البحرين استخدم عمالاً أجانب بدون تصريح وطلبت معاقبته بالمادتين (٢٣/أ ، ب ، ٣٦/أ ، ب) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ، فقضت المحكمة الصغرى الجنائية ((الثانية)) بتغريمه ألف دينار ، لم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ١١/٢٠١٠/١٧٠٧ ، وأثناء نظر الاستئناف قدم المدعي بجلسة ٢٧/٠٩/٢٠١١ مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ، والمحكمة قررت تأجيل الدعوى لجلسة ١/١١/٢٠١١ ليقدم المدعي ما يفيد إقامة دعواه الدستورية ، فأقام المدعي الدعوى الماثلة بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١١ .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة بالطريق الذي رسمه القانون على سند من أن محكمة الموضوع لم تعرض للمواد التي دُفع بعدم دستوريتهما وتقدر جدية هذا الدفع واكتفت بالتصريح للمدعي بإقامة دعواه الدستورية . فمردود ذلك أن المدعي قد دفع في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة ٢٧ سبتمبر ٢٠١١ بعدم دستورية المادة (٣٦) من قانون تنظيم العمل فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ١ نوفمبر ٢٠١١ ليقدم المدعي ما يفيد رفع دعواه أمام المحكمة الدستورية باعتبار أنها قد قدرت ضمناً جدية هذا الدفع وأرجأت الفصل في النزاع الموضوعي أمامها إلى أن يقدم المدعي ما يدل على رفع دعواه الدستورية ، أي أنها قد علقت حكمها في الفصل في الدعوى الموضوعية على الفصل في المسألة الدستورية التي أثارها المدعي ، وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بطريق الدفع خلال الأجل المحدد ووفق الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها

بالفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، فإنها تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى نص المادة (٤٠) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ المطعون فيه ، لاتصالها بالمحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون، فهو دفع صحيح، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (١٨/ ب، ج) من قانونها قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بعدم دستورتيتها تكون إما بدفع يديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - أيًا كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها - وتقدر هي جديته وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية وإما إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تشير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور ، ولم يجز المشرع بالتالي للأفراد إقامة الدعوى المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية من النظام العام فلا تجوز مخالفتها .

وإذ كان ذلك ، وكان الطعن بعدم دستورية المادة (٤٠) لم يرد بتصريح محكمة الموضوع الصادر بجلسة ٢٧ سبتمبر ٢٠١١ وهو ما يعني أنها لم تصرح للمدعي سوى برفع الدعوى بعدم دستورية المادة (٣٦) فقط من دون سواها ومن ثم يكون ما ورد بصحيفة دعواه الدستورية بشأن المادة (٤٠) طعنًا أقيم - بالنسبة إليها - بالطريق المباشر لم يتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .

وحيث إن المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل تنص على أنه :

((أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) ، (ج) من المادة (٢٣) والمادتين (٢٨) و(٣٠) من هذا القانون .

ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (٢٣) من هذا القانون .

ج- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار ، كل صاحب عمل ، أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (٣٤) من هذا القانون .

د- لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً ، لأية أضرار أو ظروف مخففة () .
وتنص الفقرة (ب) من المادة (٢٣) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ على أنه:
(يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح () .

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها إذ لا دعوى بغير مصلحة، ومناطق هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية - سواء كانت مصلحة حالة أو محتملة - وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه يوفر للمدعي مصلحة محتملة في أن تأمر محكمة الموضوع بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ أو النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لطرف مخفف ، أو لعذر مخفف قد يبيديه المدعي أمام محكمة الموضوع ، وذلك إذا ما انتهت محكمة الموضوع إلى إدانة المدعي عن الجريمة التي تضمنها قرار الاتهام ، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة في الدفع بعدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل تكون قد توافرت ، وبذا ينحصر نطاق الدعوى الدستورية - على ما يبين من أوجه مناعي المدعي - في نص الفقرة (د) من المادة (٣٦) سالفه البيان .

وحيث إن المدعي ينعى على نص الفقرة (د) أنه يحظره وقف تنفيذ العقوبة المالية وبمنعه النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لما قد يبيديه من أضرار أو ظروف مخففة أو لما قد يراه القاضي من ظرف مخفف يدعو إلى الرأفة بالمتهم يكون قد جرد القاضي من السلطة التي يقدر بها لكل جريمة عقوبتها التي تناسبها ، بما يناقض موضوعية تطبيقها ، ويعتبر تدخلاً من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية خلافاً لأحكام المادة (١٠٤) من الدستور ، كما أن النص بهذا الحظر قد أكد نية المشرع في جباية الأموال من دون مراعاة أضرار وظروف المتهم ، وهو ما يعتبر اعتداءً على ملكيته الخاصة لهذه الأموال خلافاً للحماية التي قررتها المادة (٩/ج) من الدستور لهذه الملكية .

وحيث إنه من المقرر - وفقاً لقضاء هذه المحكمة - أن الأصل الدستوري لسلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات أنه سلطة تقديرية ما لم يكن الدستور قد فرض عليه في

شأن ممارستها ضوابط محددة تحد من إطلاقها باعتبار أن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم ، موازناً بينها ومرجعاً لما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الجماعة ، واختيار أصلحها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم ، إلا أن ممارسة هذه السلطة مقيدة بضوابط الدستور وحدوده ، التي تُعدّ سياجاً لا يجوز اقتحامه أو تخطيه ، فإذا ما عهد الدستور إلى أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية بتنظيم موضوع معين ، كان لزاماً على القواعد القانونية التي تصدر عن أي منهما في هذا النطاق ألا تتال من جوهر الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور ، سواء بنقضها من أساسها بإهدارها ، أو بانتقاصها من أطرافها بتهميشها ، وإلا كان ذلك بمثابة عدوان على مجالاتها الحيوية .

وحيث إن السلطة التقديرية التي يباشرها المشرع في مجال تفريد العقوبة ، تتحقق بوسائل متعددة من بينها التدرج بالعقوبة بين حديها الأعلى والأدنى ، ومنها وقف تنفيذ العقوبة ، ومنها الخروج على هذين الحدين صعوداً ونزولاً ، فيرتفع بها عن حدها الأعلى في حالة الظروف المشددة ، وينزل بها عن حدها الأدنى في حالة الظروف المخففة ، ويخضع تقدير ذلك كله للسلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم شرعية الجرائم والعقوبات ، ولما كان الدستور قد أكد مبدأ شخصية العقوبة بنص الفقرة (ب) من المادة (٢٠) منه ، فإنه يعني به - في أحد مضامينه - تقييد المشرع بضرورة تنظيم مبدأ التفريد التشريعي للعقوبات ، وذلك لكي تتناسب العقوبة مع مدى مسئولية المتهم عن الجريمة شخصياً ودوره في الجرم عند إنزال العقوبة عليه من القاضي ، ومن ثم فلا مندوحة للمشرع ، من الناحية الدستورية ، عن إعمال التفريد للعقوبة في مجال تنظيم الجرائم والعقوبات ، وإلا كان مخالفاً لمبدأ شخصية العقوبة . إلا أن الدستور وقد ألزم المشرع بتفريد العقوبة ، لم يحدد له حداً معيناً ، عند ممارسته لسلطته في التفريد ، ولم يضع عليه قيداً في تحديد مداه ومجالاته وأسبابه ، وبالتالي ليس ثمة قيد دستوري خاص على مباشرة المشرع لسلطته تلك ، إلا الضوابط التي يفرضها الدستور في إطار تنظيم شرعية الجرائم والعقوبات ، القائم على مبدأي الضرورة الاجتماعية والتناسب في العقوبة ، ومن المقرر أن القيمة الدستورية لتفريد العقوبة مستمدة من أساس التجريم والعقاب وهو الضرورة والتناسب .

وكلما استقام الجزاء الجنائي - وتقديره عملية موضوعية - على قواعد يكون بها ملائماً ومبرراً من منظور اجتماعي ، فإن إحلال جهة الرقابة على دستورية القوانين لخيارتها محل المشرع في شأن تفريد جزاء أو تحديد مداه ، لا يكون جائزاً دستورياً ، بما مؤداه أن دور

الرقابة على دستورية القوانين التي خولها الدستور للمحكمة الدستورية يقف ، في هذه الحالة، عند مقابلة النص المطعون فيه بنصوص الدستور الشكلية والموضوعية ، لبيان أوجه مخالفتها أو اتفاقها معها ، ولا يمتد إلى بحث ملاءمة إصدار التشريع أو الباعث فيه.

وحيث إن نص الفقرة (د) من المادة (٣٦) المطعون فيه قد حظر وقف تنفيذ العقوبة المالية المنصوص عليها في هذه المادة ، كما منع النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً، لأي أضرار أو ظروف مخففة في الجرح الواردة في المادة المذكورة، فإذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه، ما يدعو إلى وقف تنفيذ العقوبة المالية أو رأت ظرفاً يدعو إلى الرأفة بالمتهم فلا تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المالية ، أو النزول بها عن حدها الأدنى ، فإن المشرع بهذا التقدير قد أجرى المفاضلة بين البدائل المختلفة لتفريد العقوبة مستهدفاً أنسبها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها وهو تحقيق مزيد من الردع العام - منظوراً إليه من زاوية تشريعية - لكل من يعلم بمضمون التجريم والعقاب في الجرائم الواردة في المادة (٣٦) صوناً لمصالح العمالة الوطنية ، فضلاً عن تحقيق الردع الخاص - منظوراً إليه من زاوية قضائية - وذلك من الملاءمات التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع في مجال تنظيم الجرائم والعقوبات وفي حدود اختصاصاته الدستورية ووظيفته التشريعية ، ولما كان الجزاء الجنائي للجريمة في النص الطعين قائماً على قاعدة التناسب والملاءمة، ومبرراً من منظور اجتماعي ، فلا يجوز للمحكمة الدستورية أن تحل تقديرها محل تقدير المشرع في شأن تقريره أو تحديد مداه.

ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها وتقديرها لها في الحدود المقررة قانوناً جبراً لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبيها .

وحيث إنه من الثابت كذلك ، أن هذا النص قد احتفظ للقاضي بسلطة تقديرية في مجال تفريد العقوبة وتطبيق الظروف المخففة على المتهمين في الجنحة محل المادة (٣٦) السالف بيانها عند توافر مبرراتها - بما يعرف بالتناسب القضائي أو التفريد القضائي للعقوبة - فيتدرج بها بين حديها الأعلى والأدنى ويباشر من خلالها سلطته في توقيع العقوبة المناسبة لمسئولية المتهم شخصياً عن الجريمة ودوره فيها ، ويقدرها حسب شخصيته وظروفه، وفي ضوء ملابساتها ، في الحدود المقررة قانوناً، فذلك هو جوهر الوظيفة القضائية ، وبالتالي إذا حرم القانون القاضي من سلطته في وقف التنفيذ في الجرح الواردة في نص المادة (٣٦) أو منعه من النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً، فإن ذلك

لا يعتبر من مكونات التفريد التشريعي الذي يمارس القاضي سلطته في التفريد في حدوده وداخل إطاره .

وحيث إن النص الطعين - وفي ضوء ما تقدم - قد أكد سلطة القاضي في تفريد العقوبة وتقديرها في الحدود المقررة قانوناً - في شأن الجرح الواردة في المادة (٣٦) - فإنه يضحى بمنأى عن شبهة المساس بجوهر الوظيفة القضائية واستقلالها المنصوص عليه في المادة (١٠٤) من الدستور أو التدخل في سير العدالة ، ولا يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (٣٢/أ) من الدستور .

وحيث إنه من المقرر أن الحماية التي أظّل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان وفقاً لنص الفقرتين (أ، ج) من المادة (٩) منه لا تنحصر في الملكية الفردية ، بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها من دون تمييز باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ، وإذ كان ذلك ، وكانت حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً للنص المطعون فيه ، تؤوّل جميعها بقوة القانون إلى خزانة الدولة - فتدوب في إيراداتها الأخرى - باعتبارها جزاءً للجريمة التي اقترفها المحكوم عليه وُضعت حماية لمصالح المجتمع ومصالح المحكوم عليه ، ولم يكن هدفها إثراء للدولة على حساب المذنب ، فلا تمتد إليها الحماية القانونية التي قررها الدستور لحق الملكية في الفقرتين سالفتي الذكر ، ومن ثم فإن النص الطعين لا ينحل - والحالة هذه - عدواناً على حق الملكية أو جباية لأموال المدعي .

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أحكام الدستور من وجه آخر .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة